

第 39 問

甲は、同じ下宿の隣室に住んでいる A が他から盗んできたカメラを持っているのを知り、これを一泊旅行の記念撮影のため一時借用しようと思い、旅行の前日、A の留守をねらって、その部屋に入った上、右カメラを持ち出し、翌日、これを持って旅行に出かけ、旅行先で写真を撮影し、旅行から戻った日に、右カメラを元の場所に返しておいた。

甲の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 昭和 61 年度 第 2 問)

1 窃盗目的で、Aの留守中にその部屋に入った点について、住居侵入罪（130前段）が成立する。なお、カメラを戻しに立ち上がった点については包括して評価すれば足りるだろう（そもそも、カメラを戻しに立ち入ることは、「正当な理由がない」とはいえない可能性もある。）。

2 カメラを持ち出した点について窃盗罪（235）の成否が問題となる。

窃盗罪の成立要件は、「他人の財物」を「窃取する」こと、それに対する認識（故意）及び不法領得の意思である。

「他人の財物」とは、242条が注意的な規定ではなく、創設的規定であることから（最決昭52.3.25）、「他人の所有する財物」であると解するのが近時の一般的な立場である。そして、本問では、元の所有者が所有するカメラであるから、「他人の財物」であることは明らかである。

次に、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいうところ、Aの意思に反してAのカメラの占有を排除し、甲の占有に移しているからこれも満たされる。

3 ただし、Aが持っているカメラは、他から盗んできたものであるから、Aに本権が無く、財産犯の保護法益論が問題となる（**論点** 財産犯の保護法益論  司H27予R3）。

もっとも、この場合に、窃盗罪の成立を否定する学説はない。

占有説からは、窃盗犯であるAの占有も保護される。また、平穏な占有説も所有者本人が取戻しをする場面ではない本件では、窃盗犯の占有も、平穏な占有に当たるとする。

一方、本権説も、元の所有者（本問でいうカメラの所有者）の追求権がさらに侵害されるため、この元の所有者の所有権が侵害されるなどとする。

近時の学説では、これは占有説・本権説の対立が問題となる場面ではないという指摘がなされているが、答案上は一応触れておいた方がよいだろう。

4 次に、不法領得の意思を検討する（**論点** 不法領得の意思  司H27,H29,旧H1-2,H19-2）。判例（大判大4.5.21、最判昭26.7.13等）・通説は、窃盗罪の成立要件として不法領得の意思を要求し、その内容として、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として（権利者排除意思）、②その経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思（利用処分意思）が必要であるとする。

本問では、①が認められるかが問題となる。夜中に自動車を5時間乗り回すつもりで、4時間後に捕まった場合に窃盗罪を認めた判例（最決昭55.10.30【百選Ⅱ32】）があるように、返還意思がある場合でも、相当程度の利用可能性を侵害する意思がある場合には、①は肯定される。

本問では、自動車に比べて価値の低いカメラが対象物となっており、また、顔見知りであると思われるAからカメラを窃取しているから、上記判例の事案よりは、①を肯定しにくい要素がある。もっとも、一泊旅行に持ち出していることから、場所的・時間的な離隔が大きく、その間A（又は元の所有者）が、カメラを使用することができなくなり、また、そのことを認識しているといえるから、相当程度の利用可能性を侵

 総合 193 頁  論証 81 頁

 総合 198 頁  論証 85 頁

害する意思があるといえる。

したがって、①を満たすというべきである。なお、旅行から戻った日に、カメラを元の場所に返しておいたという点は、不法領得の意思の有無の判断に当たって大きな意味を持たない。同意思の有無は、領得時に判断すべきものだからである（不法領得の意思を否定する方向の間接事実くらいにはなるかもしれないが。）。

5 以上より、甲に窃盗罪が成立する。

答案構成

- 1 甲がAの留守をねらって、その部屋に入った行為について、カメラを元に戻すためにAの部屋に立ち入った行為について、それぞれ住居侵入罪（130前段）成立

↓

- 2 甲が本件カメラを持ち出した点について、窃盗罪の成否（235）

↓

「他人の財物」、「窃取」

↓

窃盗罪の保護法益論

↓

占有説

↓

占有の要保護性は相対的なものである

↓

故意（38 I）

↓

不法領得の意思

↓

権利者排除意思、利用処分意思

↓

あてはめ

↓

窃盗罪成立

↓

- 3 住居侵入罪二罪は包括評価される、窃盗罪とは牽連犯となる（54 I 後段）

1 甲がAの留守をねらって、その部屋に入った行為について、「正当な理由がないのに、人の住居……に侵入し」たものとして、住居侵入罪（130条前段）が成立する。また、旅行から戻った日にカメラ（以下「本件カメラ」という。）を元に戻すためにAの部屋に立ち入った行為についても、同様に同罪が成立する。

2 次に、甲が本件カメラを持ち出した点について、窃盗罪（235条）の成否が問題となる。

(1) まず、「他人の財物」とは、他人の所有する財物を意味するところ、本件カメラは、Aが他から盗んできたものであるから、「他人の財物」であることは明らかである。

次に、「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいう。

本問では、Aの意思に反してAのカメラの占有を排除し、甲の占有に移しているから、これも満たされる。

(2) この点について、Aの占有は違法な占有であり保護に値しないのではないかという疑問があるが、占有の要保護性は相対的なものであるから、同罪成立の支障とはならない。

(3) また、甲は、Aが他から盗んできたカメラを持っているのを知り、これを持ち出しているから、故意（38条1項）に欠けるところもない。もっとも、甲は、元の場所に戻すつもりでこれを持ち出している。そのため、不法領得の意思が認められないのではないか。

まず、領得罪の成立に際し、不法領得の意思の有無を判断する必要

1

がある。かかる主観的超過傾向を不要とすれば、不可罰的な使用窃盗と窃盗罪との区別、更に、窃盗罪と毀棄罪との区別が困難になるからである。

そして、その内容としては、①権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思であると解する。後者は、要求される趣旨から考えて、毀棄・隠匿を除外した当該財物から何らかの効用を享受する意思で足りると解する。

本問では、本件カメラを一泊旅行の記念撮影のために使用しようとしているため、②が認められることは明らかである。

次に、①であるが、返還意思がある場合でも、相当程度の利用可能性を侵害する意思がある場合には、これが認められる。

そして、たしかに、本件カメラは、価値の高い物件とは言い難く、Aと甲は顔見知りであると思われる。しかし、一泊旅行に持ち出していることから、場所的・時間的な離隔が大きく、その間A（又は元の所有者）が、カメラを使用することができなくなり、また、そのことを認識しているといえるから、相当程度の利用可能性を侵害する意思があるといえる。

したがって、①も満たすというべきである。

(4) よって、甲に窃盗罪が成立する。

3 以上より、窃盗罪と住居侵入罪が成立する。二つの住居侵入罪は、Aの住居権という同一の法益に向けられた行為であって、一連の計画に基づいて行われたものであるから、包括一罪として評価されるべきで

2

ある。そして、これと窃盗罪は、目的手段の関係にあるから、牽連犯
(54条1項後段)になる。

以上

3

4